PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5007940-03.2023.8.21.0021/RS

AUTOR: DAIANI BOSCATTO
ADVOGADO(A): GLENIO LEMOS VIEIRA (OAB RS060411)
ADVOGADO(A): MARILIA DA VEIGA (OAB RS089580)
ADVOGADO(A): FLORI FRANCISCO BARRETO DO AMARAL WEGHER (OAB RS021256)
ADVOGADO(A): GLAUBER LEMOS VIEIRA (OAB RS031092)

RÉU: UNIMED PLANALTO MEDIO COOPERATIVA DE SERV MEDICOS LTDA
ADVOGADO(A): ALBANO BUSATO TEIXEIRA (OAB RS077782)

SENTENÇA

Vistos, etc.

DAIANI BOSCATTO, qualificada na inicial, ajuizou a presente *ação cominatória com indenizatória* em desfavor de **UNIMED PLANALTO MEDIO COOPERATIVA DE SERV MEDICOS LTDA**, também qualificada. Relatou que estava com 29 semanas de gestação, esperando seu primeiro filho, já tendo passado por episódio de AVC no ano de 2019, o que, na gravidez, é risco gravíssimo, tanto para mãe quanto para o nascituro. Mencionou ter plano de saúde com a ré, sendo que sua médica receitou o uso do medicamento "ENOXAPARINA SÓDICA 40mg, uma ampola por dia", objetivando evitar episódios tromboembólicos, além de complicações fetais. Sustentou que o procedimento solicitado pelos médicos assistentes não é experimental e tem comprovação científica. Alegou que o procedimento foi negado pela ré, em 20/01/2023, prática ilegal e abusiva, pois a indicação do tratamento compete tão somente ao médico assistente, bastando previsão no plano de seguro de cobertura de tramamento obstetrício. Assinalou estar suportando um custo mensal de R$2.000,00, insustentável, pois parecido com seu ganho. Discorreu sobre os fundamentos jurídicos, especialmente sobre o direito fundamental à saúde, a aplicabilidade do CDC e o dever do plano de saúde custear o tratamento, previsto contratualmente. Argumentou ter sofrido dano moral com a situação de angústia decorrente da negativa da parte ré. Requereu a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de determinar que a ré forneça as injeções receitadas por sua médica assistente, pelo período necessário. Postulou a procedência do feito, a fim de confirmar a tutela provisória de urgência e condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Requereu a gratuidade judiciária. Instruiu a inicial com documentos (evento 1, DOC1).

Deferida a gratuidade judiciária, recebida a inicial, indeferida a tutela provisória de urgência, dispensada a audiência de conciliação e determinada a citação da parte ré (evento 3, DOC1).

Comunicada a interposição de agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento (processo 5089044-32.2023.8.21.7000/TJRS, evento 20, RELVOTO1).

Citada (evento 9, DOC1), a parte ré apresentou contestação no evento 11, DOC1. Sustentou que o contrato de plano de saúde firmado tem previsão expressa de exclusão do fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, o que é o caso dos autos. Discorreu sobre o princípio do mutualismo e a necessidade de preservação do equilíbrio econômico e financeiro das operadoras de planos de saúde. Assinalou que o serviço postulado não está compreendido no Rol da Resolução Normativa n° 428/2017 ou n° 465/2021 da ANS. Sustentou que a própria lei dos planos de saúde prevê a possibilidade de exclusão do tratamento domiciliar. Indicou entendimento jurisprudencial do STJ. Impugnou os danos morais alegados pela parte autora. Postulou a improcedência do feito. Acostou documentos.

Houve réplica (evento 15, DOC1).

Intimadas as partes acerca do interesse na produção de outras provas (evento 18, DOC1), não houve requerimentos.

Vieram-me os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Passo à fundamentação.

O feito foi regularmente instruído, não havendo nulidades. Estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. A relação consumerista já foi reconhecida, tendo sido invertido o ônus probatório com relação à comprovação da legalidade da negativa de cobertura. Passo, de imediato, ao exame do mérito, diante da ausência de preliminares ou questões pendentes de apreciação.

MÉRITO

DA APLICABILIDADE DO CDC

Inicialmente, reforço que as disposições do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis ao presente caso, enquadrando-se, autora e ré, nos exatos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços preconizados pelos arts. 2° e 3°. Inclusive, este é o entendimento sumulado no verbete n° 608 do STJ:

> *"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018)".*

Ademais, trata-se de típico contrato de adesão, nos termos do art. 54 do CDC, com cláusulas pré-estabelecidas e sem margem para discussão por parte do consumidor.

DO PLANO DE SAÚDE

Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório por danos morais, na qual a parte autora insurge-se contra a negativa de fornecimento da ré ao tratamento médico a base do medicamento "ENOXAPARINA SÓDICA 40mg, uma ampola por dia", uma vez que estava em gestação de risco por passar por episódio de AVC.

Por seu turno, a contestação da parte ré está centrada na previsão expressa de exclusão de cobertura de tratamento domiciliar, como defende ser a espécie dos autos.

De plano, enfatizo que a parte autora é segurada e há cobertura para o tratamento. Ainda que, pelo tempo de tramitação do processo, possivelmente o objeto já tenha se exaurido - e aqui, ante a ausência de notícias nos autos, rogando para que a autora tenha tido uma boa hora - é necessário enfrentar a questão da possibilidade de concessão do tratamento/medicamento e da taxatividade ou exemplificatividade do rol de procedimentos e tratamentos da ANS, mormente pela análise da possibilidade de obrigar a operadora de plano de saúde a fornecer cobertura para tratamento domiciliar. E, no ponto, reafirmo o posicionamento exarado por ocasião da análise da petição inicial - tutela provisória de urgência.

DA NEGATIVA DE COBERTURA

Conforme o atestado colacionado pela autora nos evento 1, DOC4e evento 1, DOC5, depreendo que há comprovação de que o medicamento postulado (ENOXAPARINA SÓDICA 40mg), possui efeitos positivos. Há registro na ANVISA - n° 105730764[1].

Havia profunda divergência jurisprudencial no âmbito do STJ entre a Terceira e Quarta Turma[2]. Entretanto, recentemente, a Segunda Seção do Sodalício firmou entendimento no sentido de que o rol de procedimentos da ANS é, em regra, taxativo, com algumas exceções (mitigado, portanto). Eis a ementa do julgado de relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, cuja publicação ocorreu em 03/08/2022:

> *EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DE DIREITO PRIVADO ACERCA DA TAXATIVIDADE OU NÃO DO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, INEQUIVOCAMENTE ESTABELECIDA NA SUA PRÓPRIA LEI DE CRIAÇÃO. ATO ESTATAL DO REGIME JURÍDICO DE DIREITO ADMINISTRATIVO AO QUAL SE SUBMETEM FORNECEDORES E CONSUMIDORES DA RELAÇÃO CONTRATUAL DE DIREITO PRIVADO. GARANTE A PREVENÇÃO, O DIAGNÓSTICO, A RECUPERAÇÃO E A REABILITAÇÃO DE TODAS AS ENFERMIDADES. SOLUÇÃO CONCEBIDA E ESTABELECIDA PELO LEGISLADOR PARA EQUILÍBRIO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ENUNCIADO N. 21 DA I JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA À RELAÇÃO CONTRATUAL, SEMPRE VISANDO O EQUILÍBRIO. HARMONIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA PRIMEIRA E SEGUNDA SEÇÕES NO SENTIDO DE VELAR AS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E A DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA AUTARQUIA ESPECIALIZADA. FIXAÇÃO DA TESE DA TAXATIVIDADE, EM REGRA, DA RELAÇÃO EDITADA PELA AGÊNCIA, COM ESTABELECIMENTO DE PARÂMETROS OBJETIVOS PARA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS SUBMETIDAS AO JUDICIÁRIO.*
>
> *1. A Lei n. 9.961/2000 criou a ANS, estabelecendo no art. 3º sua finalidade institucional de promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e consumidores, contribuindo para o desenvolvimento das ações de saúde no País. Já o art. 4º, III, elucida que compete à ANS elaborar o Rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656, de 3 de junho de 1998, e suas excepcionalidades.*
>
> *2. Por inequívoca opção do legislador, extrai-se tanto do art. 10, § 4º, da Lei n. 9.656/1998 quanto do art. 4º, III, da Lei n. 9.961/2000 que é atribuição dessa agência elaborar o Rol de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Nessa toada, o Enunciado n. 21 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ propugna que se considere, nos contratos celebrados ou adaptados na forma da Lei n. 9.656/1998, o Rol de procedimentos de cobertura obrigatória elencados nas resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ressalvadas as coberturas adicionais contratadas.*
>
> *3. Por um lado, a Resolução Normativa ANS n. 439/2018, ora substituída pela Resolução Normativa ANS n. 470/2021, ambas dispondo sobre o rito processual de atualização do Rol, estabelece que as propostas de sua atualização serão recebidas e analisadas mediante critérios técnicos relevantes de peculiar complexidade, que exigem alto nível de informações, quais sejam, utilização dos princípios da avaliação de tecnologias em saúde - ATS, princípios da saúde baseada em evidências - SBE, manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor. Por outro lado, deixando claro que não há o dever de fornecer todas e quaisquer coberturas vindicadas pelos usuários dos planos de saúde, ao encontro das mencionadas resoluções normativas da ANS, a Medida Provisória n. 1.067, de 2 de setembro de 2021, incluiu o art. 10-D, § 3º, I, II e III, na Lei 9.656/1998 para estabelecer, no mesmo diapasão do regramento infralegal, a instituição da Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, à qual compete assessorar a ANS nas atribuições de que trata o § 4º do art. 10, devendo apresentar relatório que considerará: I - as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento, do produto ou do procedimento analisado, reconhecidas pelo órgão competente para o registro ou a para a autorização de uso; II - a avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às coberturas já previstas no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, quando couber; e III - a análise de impacto financeiro da ampliação da cobertura no âmbito da saúde suplementar.*
>
> *4. O Rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para assegurar direito à saúde, a preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável economicamente da população. Por conseguinte, considerar esse mesmo rol meramente exemplificativo - devendo, ademais, a cobertura mínima, paradoxalmente, não ter limitações definidas - tem o condão de efetivamente padronizar todos os planos e seguros de saúde e restringir a livre concorrência, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, o que representaria, na verdade, suprimir a própria existência do "Rol mínimo" e, reflexamente, negar acesso à saúde suplementar à mais extensa faixa da população.*
>
> *5. A par de o Rol da ANS ser harmônico com o CDC, a Segunda Seção já pacificou que "as normas do CDC aplicam-se apenas subsidiariamente nos planos de saúde, conforme previsão do art. 35-G da Lei nº 9.656/1998. De qualquer maneira, em casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios da especialidade e da cronologia, há evidente prevalência da lei especial nova" (EAREsp n. 988.070/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 8/11/2018, DJe de 14/11/2018). Dessa maneira, ciente de que o Rol da ANS é solução concebida pelo próprio legislador para harmonização da relação contratual buscada nas relações consumeristas, também não caberia a aplicação insulada do CDC, alheia às normas específicas inerentes à relação contratual.*
>
> *6. Não se pode perder de vista que se está a discutir direitos e obrigações da relação contratual que envolvem plano de saúde e usuário, e não o estabelecimento de obrigação de fazer ou de não fazer a terceiro, que nem mesmo integra a lide. A*

ANS, ao contrário do médico-assistente da parte litigante, analisa os procedimentos e eventos sob perspectiva coletiva, tendo em mira a universalização do serviço, de modo a viabilizar o atendimento do maior número possível de usuários. Mesmo o correto e regular exercício profissional da Medicina, dentro das normas deontológicas da profissão, usualmente possibilita ao profissional uma certa margem de subjetividade, que, por vezes, envolve convicções pessoais ou melhor conveniência, mas não pode nortear a elaboração do Rol.

7. Conforme adverte a doutrina especializada, muito além de servir como arrimo para precificar os valores da cobertura básica e mínima obrigatória das contratações firmadas na vigência da lei de Planos de Saúde, o Rol de procedimentos, a cada nova edição, delineia também a relevante preocupação do Estado em não expor o consumidor e paciente a prescrições que não encontrem respaldo técnico estudado e assentado no mundo científico, evitando-se que virem reféns dos interesses - notadamente econômicos - da cadeia de fornecedores de produtos e serviços que englobam a assistência médico-hospitalar e odontológica suplementar.

8. Legítima é a confiança que está de acordo com o direito, despertada a partir de circunstâncias objetivas. Com efeito, o entendimento de que o Rol - ato estatal, com expressa previsão legal e imperatividade inerente, que vincula fornecedores e consumidores - deve ser considerado meramente exemplificativo em vista da vulnerabilidade do consumidor, isto é, lista aberta sem nenhum paralelo no mundo, ignora que é ato de direito administrativo, e não do fornecedor de serviços, assim como nega vigência a diversos dispositivos legais, ocasionando antisseleção, favorecimento da concentração de mercado e esvaziamento da competência atribuída à ANS pelo Poder Legislativo para adoção de medidas regulatórias voltadas a equilibrar o setor de saúde suplementar de forma ampla e sistêmica, com prejuízo para toda a coletividade envolvida. Afeta igualmente a eficácia do direito constitucional à saúde (art. 196 da CF), pois a interferência no equilíbrio atuarial dos planos de saúde privados contribui de forma significativa para o encarecimento dos produtos oferecidos no mercado e para o incremento do reajuste da mensalidade no ano seguinte, dificultando o acesso de consumidores aos planos e seguros, bem como sua mantença neles, retirando-lhes a confiabilidade assegurada pelo Rol de procedimentos, no que tange à segurança dos procedimentos ali elencados, e ao Sistema Único de Saúde (SUS), que, com esse entendimento jurisprudencial, reflexamente teria sua demanda aumentada.

9. Em recentes precedentes específicos envolvendo a supressão das atribuições legais da ANS, as duas Turmas de Direito Público decidiram que, "segundo entendimento firmado neste Superior Tribunal de Justiça, até prova cabal em contrário, deve prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados pelas agências reguladoras", "sendo inviável qualquer discussão acerca do próprio mérito administrativo" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.266/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021). Ademais, assentaram que não é papel do Judiciário promover a substituição técnica por outra concepção defendida pelo julgador, sendo "incabível substituição da discricionariedade técnica pela discricionariedade judicial" (AgInt no REsp n. 1.823.636/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021).

10. Diante desse cenário e buscando uma posição equilibrada e ponderada, conforme o entendimento atual da Quarta Turma, a cobertura de tratamentos, exames ou procedimentos não previstos no Rol da ANS somente pode ser admitida, de forma pontual, quando demonstrada a efetiva necessidade, por meio de prova técnica produzida nos autos, não bastando apenas a prescrição do médico ou odontólogo que acompanha o paciente, devendo ser observados, prioritariamente, os contidos no Rol de cobertura mínima. Deveras, como assentado pela Corte Especial na esfera de recurso repetitivo, REsp n. 1.124.552/RS, o melhor para a segurança jurídica consiste em não admitir que matérias técnicas sejam tratadas como se fossem exclusivamente de direito, resultando em deliberações arbitrárias ou divorciadas do exame probatório do caso concreto. Ressaltou-se nesse precedente que: a) não é possível a ilegítima invasão do magistrado em seara técnica à qual não é afeito; b) sem dirimir a questão técnica, uma ou outra conclusão dependerá unicamente do ponto de vista do julgador, manifestado quase que de forma ideológica, por vez às cegas e desprendido da prova dos autos; c) nenhuma das partes pode ficar ao alvedrio de valorações superficiais.

11. Cabem serem observados os seguintes parâmetros objetivos para admissão, em hipóteses excepcionais e restritas, da superação das limitações contidas no Rol: 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extrarrol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

12. No caso concreto, a parte autora da ação tem esquizofrenia paranoide e quadro depressivo severo e, como os tratamentos medicamentosos não surtiram efeito, vindica a estimulação magnética transcraniana - EMT, ainda não incluída no Rol da ANS. O Conselho Federal de Medicina - CFM, conforme a Resolução CFM n. 1.986/2012, reconhece a eficácia da técnica, com indicação para depressões uni e bipolar, alucinações auditivas, esquizofrenias, bem como para o planejamento de neurocirurgia, mantendo o caráter experimental para as demais indicações. Consoante notas técnicas de NatJus de diversos Estados e do DF, o procedimento, aprovado pelo FDA norte-americano, pode ser mesmo a solução imprescindível para o tratamento de pacientes que sofrem das enfermidades do recorrido e não responderam a tratamento com medicamentos - o que, no ponto, ficou incontroverso nos autos.

13. Com efeito, como o Rol não contempla tratamento devidamente regulamentado pelo CFM, de eficácia comprovada, que, no quadro clínico do usuário do plano de saúde e à luz do Rol da ANS, é realmente a única solução imprescindível ao tratamento de enfermidade prevista na Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID, notadamente por não haver nas diretrizes da relação editada pela Autarquia circunstância clínica que permita essa cobertura, é forçoso o reconhecimento do estado de ilegalidade, com a excepcional imposição da cobertura vindicada, que não tem preço significativamente elevado.

14. Embargos de divergência a que se nega provimento.

(EREsp n. 1.886.929/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022.)

Curial destacar que não houve o trânsito em julgado da decisão, estando pendente de julgamento agravo em recurso extraordinário[3].

Porém, inobstante o cenário acima descrito, o Congresso Nacional sancionou a Lei n° 14.454/22, em 21/09/22, com vigência a partir da publicação, que, especialmente, alterou o disposto no art. 10 da Lei n° 9.656/98, com o seguinte teor:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

(...)

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022) - grifei.

In casu, portanto, tenho que ocorreu o fenômeno da superação (ou reversão) da jurisprudência da Corte Superior, não sendo caso de aplicação da tese firmada pelo STJ, cuja ementa alhures transcrevi, nos termos do art. 489, §1°, inciso VI do CPC.

Como assentou o Min. Luiz Fux, por ocasião do julgamento da ADI n° 5.105/DF[4], abordando a tese dos diálogos institucionais e os limites à reação legislativa às decisões do Supremo Tribunal Federal *"essa práxis dialógica, além de não ser incomum na realidade interinstitucional brasileira, afigura-se perfeitamente legítima — e, por vezes, desejável —, estimulando prodigioso ativismo congressual, desde que, é claro, observados os balizamentos constitucionais"* de modo que, *"ao legislador é franqueada a capacidade de interpretação da Constituição, a despeito de decisões de inconstitucionalidade proferidas pelo Supremo".*

Com efeito, conforme já destacado, a negativa apresentada pela operadora (evento 1, DOC7) encontra respaldo no contrato (evento 11, DOC2 - cláusula 38, "d") e na própria legislação de regência, não sendo exigível a prestação de serviços de atendimento domiciliar, facultada a contratação avulsa:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, ***exceto: ...***

VI - ***fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12;***

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

I - quando incluir atendimento ambulatorial:

...

c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;

II - quando incluir internação hospitalar:

...

g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;

Consoante previsto no artigo 17 da Resolução Normativa nº 465/2021, da ANS, em consonância com a Lei n° 9.656/98, é permitida a exclusão assistencial de medicamento de uso domiciliar, nos seguintes termos:

Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei nº 9.656, de 1998. Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais:

[...]

VI - ***fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos previstos nos incisos IX e X do art. 18, e ressalvado o disposto no art. 13****;*

Diante desse contexto, considerando que o medicamento é para uso domiciliar, porquanto deve ser administrado em injeção subcutânea (evento 1, DOC6), não há ilegalidade na negativa de cobertura, conforme artigo 17, inciso VI da Resolução Normativa nº 465/2021 exarada pela ANS, bem como o disposto no artigo 10 da Lei nº 9.656/98, que excluem o dever de cobertura dos medicamentos domiciliares à exceção dos antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (*home care*) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim.

Sobre o tema, colaciono recente julgado do TJRS, abordando o mesmo tipo de tratamento/medicamento versado nestes autos:

APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO POR DETERMINAÇÃO DO EGRÉGIO STJ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO ENOXAPARINA SÓDICA. AUSÊNCIA DO DEVER DE COBERTURA. MEDICAMENTO DOMICILIAR. ***Trata-se de rejulgamento, por determinação do egrégio STJ, da apelação interposta pela parte requerida, tendo em vista***

que restou desprovida, mantendo-se o julgamento de procedência da ação de obrigação de fazer, através da qual restou condenada a cobertura do medicamento denomiando CLEXANE, 60 mg, de princípio ativo ENOXAPARINA SÓDICA.É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. No caso em comento, a requerente é gestante, com diagnóstico de DHEG (Doença Hipertensiva Específica Gestacional), sendo-lhe prescrito o medicamento CLEXANE, 60 mg, de princípio ativo ENOXAPARINA SÓDICA, nos termos do laudo médico acostado no evento 1, LAUDO3 Muito embora vigente a alteração legislativa decorrente do advento da Lei nº 14.454, de 21 de setembro de 2022, a referida lei é clara ao estabelecer os requisitos para coberturas que vão além das previsões do Rol da ANS, sendo que, na espécie, não se está a amparar a negativa meramente por ausência de previsão do rol, mas, antes disso, por haver dispositivo legal que prevê, de forma expressa, a não obrigação de cobertura assistencial para medicamentos de uso domiciliar que não forem antineoplásicos, bem como medicação a ser utilizada utilizada quando houver atendimentos em Home Care.Nesse contexto, o medicamento pleiteado não se encaixa nas hipóteses de exceção expressamente previstas no 10 da Lei nº 9.656/98 e na Resolução Normativa nº 465/2021 para a cobertura obrigatória pelo plano de saúde, de modo que descabida a cobertura pretendida. precedentes. Sentença reformada. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA, EM REJULGAMENTO, POR DETERMINAÇÃO DO EGRÉGIO STJ (Apelação Cível, Nº 50007147620208210109, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 29-02-2024) - grifei.*

A par disso, afigurando-se lícita a negativa de cobertura da ré, não há que se falar em ato ilícito e responsabilidade civil, apta a ensejar a reparação por danos morais postulada. No ponto, destaco que, mesmo que houvesse entendimento sobre a abusividade da recusa, o C. STJ, possui jurisprudência firme no sentido de que a simples recusa não configura dano moral, por si só:

> *AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL. SÚMULAS 5 E 7/STJ. **1. A recusa da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral, notadamente quando fundada em razoável interpretação contratual. Precedentes.** 2. Não cabe, em recurso especial, reinterpretar cláusulas contratuais ou reexaminar matéria fático-probatória (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1717629/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 17/05/2019)*

Dessa forma, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, **JULGO IMPROCEDENTES** os pedidos formulados por **DAIANI BOSCATTO** em desfavor de **UNIMED PLANALTO MEDIO COOPERATIVA DE SERV MEDICOS LTDA**.

Sucumbente, condeno a parte autora ao pagamento da Taxa Única e despesas processuais, além de honorários advocatícios aos procuradores da parte ré, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 82, §2° do CPC, considerando a natureza do feito, tempo de tramitação e trabalho desenvolvido. Suspensa a exigibilidade dos ônus sucumbenciais em relação à parte autora, pois litiga albergada pela gratuidade judiciária, na forma do art. 98, §3° do CPC.

Interposto recurso de apelação por quaisquer das partes, considerando que não há mais juízo de admissibilidade em primeiro grau, observando-se o artigo 1.010 do Código de Processo Civil, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias. No caso de haver recurso adesivo, intime-se a parte apelada para contrarrazões no mesmo prazo. Após, subam os autos imediatamente ao E. TJ/RS.

Com o trânsito em julgado, dê-se baixa.

Publique-se. Registrado e intimado eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por **LUIS CLOVIS MACHADO DA ROCHA JUNIOR, Juiz de Direito**, em 16/9/2024, às 18:36:7, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10067819520v11** e o código CRC **0b99cf1b**.

---

1. https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/1568346?numeroProcesso=25351894171202097 ↩
2. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA (HOME CARE). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026 DO NCPC. REFORMA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. ABUSIVIDADE. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA Nº 568 DO STJ. ROL ANS. TAXATIVO. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.2. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dirimiu a controvérsia em conformidade com a atual orientação desta Corte, no sentido de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, visto que da natureza do negócio firmado.3. Consoante pacífico entendimento desta Corte, a reiteração de argumentos já repelidos de forma clara e coerente destoa dos deveres de lealdade e cooperação que norteiam o processo, a ensejar a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil/2015 (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.661.484/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 23/2/2018). Além disso, qualquer outra análise acerca do caráter procrastinatório dos embargos de declaração, que ocasionou a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do NCPC, seria imprescindível a análise fático-probatória, o que é inviável em recurso especial, por força do óbice da Súmula nº 7 desta Corte.4. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, em recentíssimos julgados, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos.5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.6. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1924587/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021) ↩
3. https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?src=1.1.3&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&num_registro=202001916776. Acesso em 07/10/23. ↩
4. ADI 5105, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 01/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 15-03-2016 PUBLIC 16-03-2016. ↩